

1500477-97.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude da ação dos policiais e, no mérito, pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500477-97.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2095137/2020 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 10988586 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1328/20/922 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2095137 - 04º D.P. PIRACICABA, 1328/20/922 - 04º D.P.

PIRACICABA, 2095137/2020 - 04º D.P. PIRACICABA, 2095137 - 04º D.P. PIRACICABA,

1328/20/922 - 04º D.P. PIRACICABA, 2095137 - 04º D.P. PIRACICABA, 1328/20/922 - 04º

D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYNAN SCHEMINSKI

Contr. nº 2020/000545

Aos 10 de novembro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara

Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu KAYNAN SCHEMINSKI. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS WANDERSON

ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO e Karina Marcelino Hobus

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s)

documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito

pelas partes - imagem(ns) exibida(s) durante audiência.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Pms Karina e Wanderson) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. KAYNAN SCHEMINSKI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processados como incurso no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 18 horas e 50 minutos, na rua das Seringueiras, altura do nº 56, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, KAYNAN trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 21 eppendorfs contendo cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 21,7g, e 8 invólucros plásticos contendo maconha (Cannabis sativa L.), com peso bruto aproximado de 19,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 16/22). É da inicial que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local mencionado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu em atitude suspeita. Assim sendo, decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, foi encontrada sob as vestes de KAYNAN, na região da cintura, uma sacola plástica contendo as substâncias entorpecentes discriminadas, prontas para a venda, bem como a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro trocado. Nesse contexto, o réu foi preso em flagrante delito. As circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade de drogas indicaram sua destinação ao tráfico. 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 79, 95, 102/107, 124/125 e 146/147. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/10, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografias de fls. 13 e laudos de constatação de fls. 16/22 e toxicológico de fls. 130/132. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. O Pms Karina e Wanderson explicaram que estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde o réu se encontrava. KAYNAN foi abordado porque já era conhecido e estava em ponto de venda de entorpecentes. Ele tentou sair repentinamente do local onde estava. Abordado, o réu tinha em seu poder as porções de drogas e o dinheiro citados na denúncia. No interrogatório policial, KAYNAN disse que estava pela via pública na posse de algumas "parangas", quando foi abordado por policiais militares e acusado de estar traficando. Disse que as drogas eram para seu consumo. No interrogatório judicial, o acusado disse que estava com seu primo. Parou na "esquina da 18" e o "de menor" forneceu a maconha. O "de menor" correu, mas foi perseguido e detido pelos policiais. Nesse contexto, os PM disseram que "iriam jogar tudo no cu" do interrogando, que era o único maior de idade no local. Já conhecia o PM Azevedo e tinha desavença com ele. Apesar da negativa do réu, ficou evidente, nos depoimentos dos servidores públicos, que a droga apreendida pertencia ao acusado. Não há razão para duvidar do que disseram. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso cometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

17/11/2014). No panorama dos autos, a condenação é de rigor. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores (fls. 77/78). 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu como incurso no art. 33 da LD.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz KAYNAN SCHEMINSKI vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o acusado foi preso em flagrante após sofrer abordagem dos policiais militares que suspeitaram de sua conduta. Ocorre, porém, que ao explicarem os motivos que os levaram a suspeitar do réu, os militares apenas disseram que ele estava em local conhecido como ponto de tráfico e que tentou deixar o local ao ver a viatura. De fato, como cediço, a revista pessoal é medida excepcional que só pode ser justificada diante da existência de fundada razão de que a pessoa abordada esteja em posse de arma proibida, objeto ou papéis que constituam o corpo de delito (art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal). Ou seja, para haver a busca pessoal, deve haver “fundada suspeita” da ocultação de algum objeto ligado ao crime. Mas isso não aconteceu. Na verdade, antes da abordagem, não existia qualquer dado concreto – e objetivamente aferível – de que o réu estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente (ou qualquer outro delito). A abordagem dele se deu mediante critério meramente subjetivo, o que não é suficiente para autorizar a busca pessoal, sob pena de violação ao direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF). Apenas para ilustrar, o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu como ilegal a busca pessoal efetivada após um suposto “nervosismo” da pessoa abordada, o que pode ser aplicado perfeitamente ao caso em apreço. “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no “nervosismo” apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). E, como se observa, o entendimento do Tribunal Superior é no sentido que o fato do crime em questão (tráfico de drogas) ser classificado como permanente não importa, pois a suposta infração penal só veio à tona depois de uma abordagem feita a partir de mera conjectura. Trata-se na verdade daquilo que se tem chamado de fishing expedition (pescaria probatória), isto é, os agentes policiais realizam diversas abordagens meramente especulativas – muitas vezes fundadas em estereótipos criminais – com o intuito de encontrar algum objeto ilícito, ensejando assim a prisão da pessoa “suspeita”. Não existia uma causa provável e o encontro das drogas se deu de maneira meramente fortuita. Portanto, a conduta dos agentes policiais que realizaram a abordagem/revista pessoal no acusado sem a existência de justa causa deve ser considerada ilegal. E

uma vez reconhecida a ilicitude, todos os demais elementos derivados da busca igualmente devem ser considerados como ilegais, o que deve resultar na absolvição do réu, por ausência de provas válidas. Afinal, é evidente o nexó existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. Isso porque ainda que se entenda que o réu estava em poder das substâncias entorpecentes, nada se produziu a respeito da destinação mercantil, a qual não pode ser simplesmente presumida. Como salientado, os policiais não explicaram satisfatoriamente o motivo da abordagem, já que os locais de venda de drogas também são frequentados por usuários. Do mesmo modo, a droga é comprada na mesma embalagem em que vendida. Além disso, no caso em apreço não foi apreendida quantidade significativa de substância entorpecente, o que enfraquece a tese acusatória da ocorrência de tráfico. Logo, se caso Vossa Excelência entender pela condenação do réu, a sua responsabilidade deve ser apenas pela prática do crime de porte de entorpecente para consumo pessoal. Por fim, caso no entanto ocorra a condenação pelo crime mais grave, requer-se seja fixada a pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa, já que o acusado possuía dezoito anos à época dos fatos. Requer-se, ainda, seja aplicada a causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois preenchidos todos os requisitos legais. Consequentemente, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal, em caso de conversão. Se não reconhecida a minorante, requer-se seja fixado, ao menos, o regime semiaberto. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja permitido eventual recurso em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

KAYNAN SCHEMINSKI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 18 horas e 50 minutos, na rua das Seringueiras, altura do nº 56, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 21 eppendorfs contendo cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 21,7g, e 8 invólucros plásticos contendo maconha (*Cannabis sativa* L.), com peso bruto aproximado de 19,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 16/22).

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local mencionado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o acusado em atitude suspeita. Assim sendo, decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, foi encontrada sob as vestes de Kaynan, na região da cintura, uma sacola plástica contendo as substâncias entorpecentes discriminadas, prontas para a venda, bem como a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro trocado. O acusado foi preso em flagrante delito. Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade de drogas indicaram sua destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fl. 95). Defesa preliminar apresentada às fls. 102/107. Após, a denúncia foi recebida (fl. 124/125) e o réu foi citado (fl. 142).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude da ação dos policiais e, no mérito, pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico

de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 07/10;
- 2) auto de exibição e apreensão de fl. 11/12 e fotografia de fl. 13;
- 3) laudo de constatação de fls. 16/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 81/83, com resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04/05), o réu negou o crime. Admitiu que, quando abordado pelos policiais, trazia consigo algumas “parangas” de maconha, mas afirmou que eram para seu consumo. Os policiais, entretanto, acusaram-no de estar traficando. Disse desconhecer a origem e propriedade das demais drogas apresentadas na delegacia. Interrogado em juízo (gravação), novamente negou o tráfico, dizendo que no dia dos fatos tinha acabado de chegar do serviço. Estava com o primo e foram comprar drogas. Pararam na esquina da 18 e comprou 8 parangas de maconha de um menor.

Quando os policiais se aproximaram, o traficante correu. Um dos policiais abordou o menor e ele negou o tráfico, bem assim a posse de drogas. Como não encontraram nada com o menor, resolveram prendê-lo. Disse que, quando era menor de idade, já havia sido abordado anteriormente pelo policial Azevedo e um outro PM, os quais o agrediram e o ameaçaram, dizendo que “ia ver quando fizesse 18 anos”.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase extrajudicial (fl. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), a policial militar Karina Marcelino Hobus declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo bairro e, quando passaram pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, viram o acusado parado em atitude suspeita e perceberam que, assim que notou a aproximação da viatura, ele tentou sair do local repentinamente. Abordaram-no e, na revista pessoal, seu parceiro encontrou uma pequena sacola escondida sob suas vestes, na região da cintura, dentro da qual havia 8 porções de maconha, 21 pinos de cocaína e R\$ 40,00 em notas trocadas. Disse que o acusado não se manifestou sobre a propriedade e destinação das drogas.

No mesmo sentido as declarações do policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, ouvido na delegacia de polícia (fls. 03) e nesta data (gravação).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em

homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo as drogas descritas na denúncia, as quais eram destinadas ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, o réu foi surpreendido pelos policiais militares parado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, esboçou reação de fuga ao notar a aproximação da viatura e, com ele, foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína e dinheiro trocado, tudo a indicar a traficância.

Não há como se acolher a tese de ilicitude da ação dos policiais na abordagem do acusado. O crime de tráfico, na modalidade trazer consigo, é permanente. No momento dos fatos, havia sérios indícios de que o réu estava parado no ponto de tráfico realizando o comércio ilegal, pois, além do fato de estar parado em conhecido ponto

desse tipo de comércio, ele esboçou reação de fuga ao notar a aproximação da viatura. Evidente, nesse contexto, que estava postado naquele para comercializar entorpecentes, o que ensejou a diligência de abordagem.

Registre-se que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade e variedade de drogas (8 porções de maconha e 21 porções de cocaína), incompatível com a situação de meros usuários e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografias de fls. 13)

Outrossim, o réu trazia consigo o valor de R\$ 40,00 em notas trocadas e não comprovou a origem lícita do dinheiro, o que confirma que era oriunda do tráfico. Registro que ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, como ele alegou, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentarem o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado -

Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e de bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 74/75 e certidões de fls. 77/78).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade, mas deixo de diminuir as penas, uma vez que já fixadas no mínimo legal.

Inexistem agravantes nem causas de aumento.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções. Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu KAYNAN SCHEMINSKI a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.